

1502937-48.2020.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... as penas previstas para o crime de tráfico, e, por fim, a aplicação do princípio da insignificância.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 273, §1º-B, inciso V, do Código Penal foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação da ré.

A materialidade é comprovada pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502937-48.2020.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502937-48.2020.8.26.0408

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUANA APARECIDA PINHEIRO KIRDEIKA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira

Vistos.

LUANA APARECIDA PINHEIRO KIRDEIKA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 273, § 1º-B, inciso V, do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 17 de setembro de 2020, às 18h40min, na Rua José Vendramini, n.º 340, na Vila Boa Esperança, 2ª Secção, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, a ré, importou e tinha para a venda Cytotec, medicamento de procedência ignorada, cuja venda é proibida em farmácia, bem como é proibida a aquisição por pessoa física, produto esse destinado a fins terapêuticos e medicinais, sem registro e licença do órgão de vigilância sanitária com atribuição respectiva.

A decisão de fl. 53 recebeu a denúncia, no dia 21 de janeiro de 2021.

A ré constituiu defensora (fl. 61), que apresentou defesa preliminar (fls. 71/87).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 105).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma comum e a ré foi interrogada.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da ré nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa

requereu a absolvição sumária, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da excludente de erro sobre a ilicitude do fato, o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena imposta às condutas do artigo 273 do Código Penal, mediante a alteração decorrente da Lei 9.677/98, aplicando de forma analógica as penas previstas para o crime de tráfico, e, por fim, a aplicação do princípio da insignificância.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 273, §1º-B, inciso V, do Código Penal foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação da ré.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 05 e pelos laudos periciais de fls. 32/34.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações da ré, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogada em juízo, a ré afirmou que comprou os comprimidos em uma banca, no Braz, na cidade de São Paulo. Disse que pediu Misoprostol e que não sabia que o que lhe foi vendido era Cytotec. Afirmou que comprou porque tinha muita dor de estômago e que não tomou na hora, pois iria viajar de ônibus e teve receio de dar alguma reação. Disse que procurou a indicação do medicamento no Google e não tinha conhecimento de que se tratava de Cytotec.

A testemunha Jhonatan Yuri Feliciano de Souza afirmou que deu carona para a ré, que chegou de viagem com as compras para a sua loja, quando foram abordados pelos policiais militares, porém não tinha conhecimento de que ela trazia os comprimidos que foram apreendidos. Afirmou que não encomendou os comprimidos de Cytotec.

Os policiais militares Carlos Alexandre Cornélio e Flávio Roberto Quintana de Faria afirmaram que receberam uma denúncia de que uma mulher morena, de aproximadamente trinta anos, chegaria de ônibus, nas proximidades do Posto Machado, e que traria comprimidos abortivos para um indivíduo que estaria à sua espera em um veículo Fusion, de cor preta. Disseram que patrulharam nas imediações do posto que visualizaram a ré, que tinha as mesmas características descritas na denúncia, fazendo contato com um indivíduo que estava no veículo Fusion. Narraram que abordaram a ré, que confessou que trazia os comprimidos, que haviam sido encomendados por Jhonatan, que por sua vez confirmou que havia encomendado os comprimidos porque havia tido um relacionamento extraconjugal e que a mulher havia engravidado.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese defensiva que pretende a descaracterização da conduta criminosa da ré, tendo em vista a sua confissão de que adquiriu os comprimidos em uma banca no bairro do Brás, na cidade de São Paulo, o que por si caracteriza a conduta típica que lhe foi imputada na denúncia.

Inviável o acolhimento da tese de que a ré incidiu em erro, tendo em vista a sua própria conduta de adquirir em uma banca os comprimidos, que, ainda que não fossem de origem ignorada, seriam de venda exclusiva em farmácias.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pela ré LUANA APARECIDA PINHEIRO KIRDEIKA, do crime previsto no artigo 273, § 1º-B, inciso V, do Código Penal.

Passo à aplicação de sua pena.

Não se justifica a alegação defensiva de inconstitucionalidade da pena prevista ao artigo 273, § 1º-B, do Código Penal para fins de absolvição da ré, mas sim para o fim de se aplicar à referida conduta a pena prevista para as condutas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (STJ HC n.º 353.248 Relator: Ministro Jorge Mussi - 5ª Turma - DJ 19.05.2016).

"Finalmente, quanto à aventada desproporcionalidade da pena imposta ao paciente, ao julgar a arguição de inconstitucionalidade formulada no HC n. 239.363/PR, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário da norma do artigo 273, § 1º-B, inciso V do Código Penal, tendo o acórdão restado assim ementado:

'ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1º-B, V, DO CP. CRIME DE TER EM DEPÓSITO, PARA VENDA, PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A intervenção estatal por meio do Direito Penal deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade, incumbindo também ao legislador o dever de observar esse princípio como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. 2. É viável a fiscalização judicial da constitucionalidade dessa atividade legislativa, examinando, como diz o Ministro Gilmar Mendes, se o legislador considerou suficientemente os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais. 3. Em atenção ao princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5º, LIV), é imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir o exagero e ajustar a pena cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1º-B, do Código Penal. 4. O crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada é de perigo abstrato e independe da prova da ocorrência de efetivo risco para quem quer que seja. E a indispensabilidade do dano concreto à saúde do pretense usuário do produto evidencia ainda mais a falta de harmonia entre o delito e a pena abstratamente cominada (de 10 a 15 anos de reclusão) se comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas - notoriamente mais grave e cujo bem jurídico também é a saúde pública. 5. A ausência de relevância penal da conduta, a desproporção da pena em ponderação com o dano ou perigo de dano à saúde pública decorrente da ação e a inexistência de consequência calamitosa do agir convergem para que se conclua pela falta de razoabilidade da pena prevista na lei. A restrição da liberdade individual não pode ser excessiva, mas compatível e proporcional à ofensa causada pelo comportamento humano criminoso. 6. Arguição acolhida para declarar inconstitucional o preceito secundário da norma' (AI no HC 239.363/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 10/04/2015).

Diante de tal decisão, a 5ª e a 6ª Turma passaram a determinar a aplicação do preceito secundário contido no artigo 33 da Lei 11.343/2006 aos casos em que o acusado é condenado pelo crime previsto no artigo 273, § 1º-B, do Código Penal. Confira-se:

'HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 16, CAPUT, VÁRIAS VEZES, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 273, § 1º-B, III E VI, DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. CONDENAÇÃO POR DOIS CRIMES PELO MESMO FATO. TEMA NÃO SUSCITADO/ENFRENTADO NA ORIGEM. COGNICÃO. INVIABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 273, § 1.º, III E VI, DO CP. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1º-B, DO CP (AI NO HC Nº 239.363/PR). NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Não é possível a esta Corte debruçar-se sobre tema não enfrentado pela Corte local, sob o risco de supressão de instância. Na espécie, a matéria relativa ao suposto constrangimento ilegal - paciente teria sido condenado por dois crimes (art. 273 do CP e art. 33 da Lei nº 11.343/06) pelo mesmo fato - não foi sequer suscitada perante o Tribunal a quo. 3. A Corte Especial, por meio do julgamento da AI no HC n. 239.363/PR, por maioria, acolheu a arguição para declarar inconstitucional o preceito secundário do artigo 273, § 1.-B do Código Penal. 4. In casu, tendo em vista que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 273, § 1.-B, III e VI, do CP, de rigor que a Corte local proceda a novo julgamento do recurso de apelação, diante da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do mencionado artigo. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento da Apelação nº 0021719-39.2010.8.26.0050, a fim de que seja refeita a dosimetria da pena, apenas, no tocante ao crime previsto no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, eis que o preceito secundário do referido dispositivo foi declarado inconstitucional' (HC 327.520/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

'PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 273, § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL.

APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. Em atendimento aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, ao delito previsto no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, deve ser aplicado o preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06, conforme decidido pela eg. Corte Especial no julgamento de arguição de inconstitucionalidade formulada no HC n. 239.363/PR (AI no HC n. 239.363/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 10/4/2015). Agravo regimental desprovido' (AgRg no REsp 1549987/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 11/11/2015).

Na espécie, o paciente restou condenado à pena 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, como incurso no artigo 273, § 1º-B, inciso I do Código Penal.

Assim, em atenção ao que decidido pela Corte Especial deste Sodalício, impõe-se o refazimento da dosimetria da sanção cominada ao acusado no tocante ao referido ilícito, a fim de que seja considerado o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que também constitui crime hediondo, de perigo abstrato, e que visa a tutelar a saúde pública.

Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível, não se conhece do writ, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, apenas para determinar que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região refaça a dosimetria da pena cominada ao paciente quanto ao delito previsto no artigo 273, § 1º-B, inciso I do Código Penal, aplicando o preceito secundário do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

É o voto."

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e sopesados os critérios por este estabelecidos, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista a ausência de agravantes.

Em terceira fase, considero a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Considera-se que a ré não ostenta antecedentes e que há qualquer informação sobre o seu envolvimento em esquema de distribuição de medicamentos. Considera-se também, a respeito da quantidade de comprimidos apreendidos, o que constou da ementa do AI no HC n.º 239.363/PR, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, da Corte Especial, julgado em 26/02/2015 e publicado no DJe de 10/04/2015: "O crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada é de perigo abstrato e independe da prova da ocorrência de efetivo risco para quem quer que seja. E a indispensabilidade do dano concreto à saúde do pretendo usuário do produto evidencia ainda mais a falta de harmonia entre o delito e a pena abstratamente cominada (de 10 a 15 anos de reclusão) se comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas - notoriamente mais grave e cujo bem jurídico também é a saúde pública".

Sob tais fundamentos, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 na sua proporção máxima de 2/3 (dois terços), resultando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, e uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser recolhido à conta vinculada ao juízo para posterior repasse às entidades cadastradas, mediante a apresentação de projeto. Em caso de conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, fixo o regime aberto para o início do seu cumprimento.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO a ré LUANA APARECIDA PINHEIRO KIRDEIKA, como incurso no artigo 273, § 1º-B, inciso V, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, calculados no seu valor unitário mínimo a ser corrigido a partir da data do fato.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, e uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser recolhido à conta vinculada ao juízo para posterior repasse às entidades cadastradas, mediante a apresentação de projeto. Após o trânsito em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para os fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA